

Michael J. Perry, What is “the Constitution”?
(and Other Fundamental Questions),
什麼是「憲法」及其他基本問題

載 LARRY ALEXANDER (ED.), CONSTITUTIONALISM: PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS (Larry Alexander ed.) 99~151 (1998)

摘要
湯德宗 2026/03/02

[p/99] 序言 (opening paragraph)

二戰後困擾美國人的**道德衝突 (moral conflicts)**，如種族隔離、積極平權措施 (affirmative action)、以性別為基礎的歧視、同性戀、墮胎、醫生幫助自殺等，都轉化成**憲法上的衝突 (constitutional conflicts)**，且 (至少部分是) 根據憲法第 14 修正案來解決。這些爭議中，如果被理解為憲法衝突的話，究竟有哪些確實是 (一如其應該是) 以憲法為基礎而獲致解決的？想探究這個問題之答案者，須先回答**三個問題**：什麼是**憲法**？**解釋憲法**是什麼意思？就**憲法解釋而言**，**最高法院真的是最高**？

I. 什麼是憲法？

A. **憲法₁**與**憲法₂**之意義 (「憲法」雙義)

[p/99] **憲法₁**指憲法**文本 (the text)**。**憲法₂**指構成「斯土 (效力) 最高之法」(the supreme Law of the Land) 的**規範 (the norms)**。前者無爭議，不表示後者無爭議。

[p/100] 什麼是**憲法₂**？由哪些規範所構成？憲法前言：「我們美國人民，為了美國，茲下令並建立本憲法」。美國的憲法文化下，幾乎無人不同意：**憲法₂至少包含一些由所謂「我們人民」(we the people) 所發佈的指令 (directives)**，因為這些指令係由「我們人民」(we the people，按即**制憲/修憲先賢們**) 所發佈的。**但這並不意味只有「我們人民」(we the people) 才能建立憲法規範 (詳後 I.C.)**。

「我們人民」(we the people) 建立了哪些憲法規範？當「我們人民」(we the people) 透過代表，行諸文字，載在**憲法₁** (文本)，旨在發佈**憲法指令 (誠命) (constitutional directives)** — 即「我們人民」(we the people) 經由該文字所**表達與理解的規範**。建立規範以統治未來，乃可理解的人類行為。

B. 何以屈服於舊的憲法指令？又為何發佈新的憲法指令？

[p/101] 下命並建立 1787-1789 憲法及 1789-1791 人權條款 (按：第 1 至第 10 憲法增修條文的，以及內戰後修改憲法的「我們人民」(修憲者) 早已亡故，何以如今活著的「我們人民」卻須接受他們所發佈的憲法指令，作為「斯土 (效力) 最高之法」？我們之中的某些人認為某項由他們所發佈的憲法指令不應該成為憲法的一部分，卻仍須服從，直到我們**能依照憲法所定之方式將其廢**

止？換言之，何以我們須遵循憲法指令所建立的慣例（憲法第 5 條規定的憲法修改程序）？依循憲法第 5 條所規定之方式修改憲法，即是依照憲法所建立的慣例（convention）來行事。然，我們何以不能以憲法所未規定之方式，來建立新的憲法指令？

吾人之所以服從（既有的）憲法指令，除非（或直到）其被依循憲法所規定的方式廢止時為止，主要是基於務實（practical）的考慮。[契約一般依賴外部制裁，憲法則幾乎全賴預設，蓋違約之成本過高於高昂，乃不得不如此！]

[p/102] 以憲法所未規定的方式，廢除（舊的）憲法指令，或建立（新的）憲法指令，就是試圖違約（trying to renege on the arrangements）。違約要能成功，必須夥同足夠的他人，建立替代方案；而這通常是所費不貲的。但，無可否認的是，在非常情況（如革命、內戰或經濟大蕭條）時，也可能會以憲法所未規定的方式，建立（新的）或廢止（舊的）憲法指令。Bruce Ackerman 教授曾（成功地）說明：the 14th Amend. 既非完全依循憲法第 5 條所規定之程序，由國會提出，亦非完全依循憲法第 5 條所規定之程序由各州批准。此外，在某些情形下，最高法院也會以憲法所未規定的方式，建立（新的）或廢止（舊的）憲法指令。

有什麼理由，欲以修憲的方式，而不僅是循一般立法的方式，來建立「憲法指令」？

[p/103] 法律之修改一般僅需國會之（普通）多數，然各國憲法對修憲的要求一般皆高於國會的（普通）多數。憲法第 5 條規定：「須有參、眾兩院各 2/3 以上之決議，始得提出憲法修正案，或須經全國 2/3 以上各州請求，始得召開修憲大會，提出憲法修正案；並須經全國 3/4 以上州之批准，或經修憲大會代表 3/4 以上之批准，始得通過憲法修正案」。故，以修憲方式建立「憲法指令」，意在使自己及後代子孫將來難以廢除該項指令，亦即僅能以超級多數（supermajority），經由修憲的非常政治（extraordinary politics）作成決定。

為什麼要把廢除憲法指令變得如此困難？也許是懷疑一般（普通）多數決的政治不能適切地守護憲法指令；也許是害怕（擔心）我們將來可能失去政治上的主導地位，而繼任者可能不樂見該項憲法指令；也許是害怕（擔心）我們將來雖仍維持政治上的主導地位，但政治上的代議士可能無法適當地守護憲法指令。總而言之，就是不信任未來的政治。

{Q 不信任未來政治，應信任司法解釋？}

也可能是基於其他理由，而尋求憲法策略（constitutional strategy，即以修憲的方式來確立憲法指令）。例如：某政治社群希望建立（或重建）基本機構（或稱「基本建制」basic institutions，按：如我國之五院體制）與機構間之安排（institutional arrangements，按：如我國之「五權分治、平等相維」），以便展開尋常政治的運作；或希望將某些議題排除於尋常政治之外（使之無從干預），因為這些議題的爭辯可能會摧毀社群的連結（按：指造成社會分裂）；或僅因該社群認為某一憲法指令極為重要，而懷疑尋常的政治能夠適切地維護該指令。

C. 憲法₂包含哪些規範？

[p/104] 憲法學者幾乎無人不同意：憲法₂實際包含了某些可能並非由「我們人民」所建立的基本規範（Fundamental norms）。

在什麼情形下，如果有的話，聯邦最高法院得正當地根據憲法中某些**非**由「我們人民」（經由其政治上的代表）所建立的基本規範，廢棄法律或政府行為？一般認為是「我們人民」，而非「最高法院法官」，應下令並建立（ordain and establish）美國憲法。那麼，聯邦最高法院究竟是依據什麼權利（按：權力），將某些**非**由「我們人民」所建立的基本規範，加諸於其他權力部門（甚或各州）之上？

{Q 作者反對「法官治國」？}

這個問題和最高法院宣告法律或其他權力部門之行為違憲，究竟是因為什麼原因無關——例如，係因該院「誠實但錯誤」地解讀了憲法條文（文本）所建立的規範（意旨），或因該院「謊稱」某憲法條文（文本）所建立的規範，或因該院對不確定的憲法規範作了「不合理的具體化」（unreasonable specification），甚或是因為該法院係依據某種「憲法裁判理論」等——而以憲法之名，執行了某種無人能合理理解的憲法文句所建立的規範。我的問題是：

[p/105] 在什麼情形下，今日的最高法院應默許，而非推翻，某個舊的判決？幾乎沒有憲法學者堅持：最高法院，無論如何，概不得默認其現在認為是錯誤的、舊的憲法判決。有爭議的只是，何時（或在如何條件下）應予默認。

茲僅就其中一種可能，予以申論。如果，隨著時間的推移，某種實踐（practice）或某個舊的且錯誤的判決所建立的實踐（practice）或前提（premise）業已臻於確定，且為現今美國人民普遍肯認並依賴，而成為政治社群的生活特徵（feature of the life of our political community）時，則該前提或實踐即已取得「事實上的憲法地位」（a virtual constitutional status），而成為吾人政治社群基本法（fundamental law）的一部分。這樣的前提或實踐目前便不應由最高法院再予推翻！（即使保守如）Robert Bork 也認為：某些錯誤的憲法判決先例「因為已經如此深植於國家的生活，深為社會所接受，對個人與機構之私的與公的期待如此之根本，致其結果現在不應予以變更」，蓋憲法第 5 條規定的修憲程序要求超級多數決（supermajority），倘允許最高法院推翻如此根深蒂固的前提或實踐，無異於使得少數人即可阻止將該前提或實踐重建為憲法的一部分。{Q Homework: 此話怎講？} 這樣的前提或實踐，包括：

[p/106] • 由最高法院所建立的「整併法學」（“incorporation” jurisprudence）——為保障人民得以對抗聯邦政府，憲法以「人權清單」（Bill of Rights，即增修條文第 1 至第 10 條）所規定的各種「特權與或豁免」（即各種「權利與自由」（the “privileges and immunities”- the rights and freedoms-），人民亦得經由增修條文第 14 條，用以對抗各州政府（按：即以第 14 修正案（14th Amend.）整併了人權清單——憲法增修條文第 1 至 10 條的內容）。

• 不僅聯邦政府不得，各州政府亦不得，設立宗教、禁止宗教的自由行使、或剝奪言論自由或出版自由。[See n. 28] 但 Jay Bybee 以為：即使認為增修

條文第 2 條至第 8 條所規定的內容，乃人民本於公民身分所具有的「特權與或豁免」(the “privileges and immunities”—any privileges and immunities that persons were thought to have in virtue of their status as citizens)，前述最高法院所建立的「整併法學」之範圍，也不應及於增修條文第 1 條 (the 1st Amend.)，蓋該條明文禁止「聯邦國會」(而非「各州議會」)制定法律，剝奪人民的言論、出版、宗教、結社自由。

• 增修條文第 14 條 (The 14th Amend) 禁止各州政府進行歧視—所謂「反歧視」規範，亦適用於聯邦政府 (按：是即所謂「反向整併法學」，reverse incorporation jurisprudence—以第 5 修正案 (5th Amend.) 整併了第 14 修正案 (14th Amend.) 的反歧視規範)。儘管，第 5 修正案明明規定的是「正當程序」(Due Process)，依照修憲者(「我們人民」)的理解，很難認為其有包含「反歧視」規範的意思，這樣的「整併」說法顯得很牽強。(Perry 曾於另文主張：得經由增修條文第 9 條 (the 9th Amend.) 確立聯邦政府所應適用的「反歧視」規範)

[p/107] 以上三者俱已成為憲法之基石 (const'l bedrock)，如今最高法院便不應再予變更。

以上乃最高法院應默認 (繼續維持) 錯誤的憲法判決先例的「充分條件」(a sufficient condition)，而非「必要條件」(a necessary condition)。至其是否亦應成為「必要條件」，我尚不確知。

{Q 如上區分之實益？}

11. 何謂解釋憲法？(解釋憲法意何所指？)

A. 解釋憲法₁

[p/107] 欲宣告某項政府行為 (如某個州法) 違憲，最不具爭議的作法就是依據由「我們人民」所建立的憲法法 (憲法₂) 為之。

[p/108] 有時，憲法文義明確且歷久不變。此時，憲法₁ = 憲法₂。例如：未滿 35 歲不得選總統；美國參議院以每州兩名代表組成。

有時，憲法文義模糊，關於制憲/修憲者所欲表達之規範為何，非經過一番解釋性探索 (interpretive inquiry)，無法確知。例如：何謂第 1 修正案 (the 1st Amend) 所謂「政府不得禁止宗教之自由行使」(prohibit the free exercise of religion)？1990 年有五位最高法院大法官認為：該條之規範僅在禁止歧視性的行為 (discriminatory action)。到了 1993 年，還有四位最高法院大法官，連同制定及簽署「宗教自由回復法」(Religious Freedom Restoration Act) 的國會與總統，認為「宗教自由行使」的規範僅在禁止某些妨礙宗教之自由行使的歧視性行為。

[p/109] 其次，第 14 修正案第 1 項 (Sec. 1, 14th Amend.) 所謂 (各州不得制定或執行立法，剝奪)「美國公民之特權暨豁免」(the privileges and immunities

of citizens of the United States)，究何所指？非經一番費力的解釋探索，現在的「我們人民」無法知悉經歷過內戰與廢奴世代的「我們人民」，究竟希望以「美國公民的特權暨豁免」一詞，表達什麼意思。包括：所謂「特權暨豁免」的內涵為何？該項規定旨在保護人民免於什麼樣的州立法？係不得以種族為基礎，進行歧視的立法？[p/110] 誰應受到該項規定的保護？如同 John Ely 所說：「各州不得制定或執行立法剝奪美國公民之特權暨豁免」，其中「公民」二字可理解為界定不得剝奪的權利種類（即僅限於「公民的特權暨豁免」），而非指受益的「群體」（公民）。

為瞭解「我們人民」當初載入憲法的文字所欲傳達的規範意旨，有時讀者需進行歷史探索。如同 John Ely 所說：「除非我們知道對於美國父母（American parents）而言，或者對於『出生時已婚之父母』（born married parents）而言，『本國出生』（natural born）是什麼意思，我們不知道當初批准憲法第 2 條第 1 項的人在想些什麼，從而認知憲法之「誡命」（指令）為何。」

解釋憲法之規定（文本）—探問制憲或修憲者所欲建立之規範意旨為何，有時會與另外一項探索—依制憲或修憲者所信，目前困擾我們的規範衝突應如何解決方為正辦—相互混淆。後者雖非無關，蓋瞭解前人以為正確的解決方法，可以幫助我們確認系爭規範的範圍；但最重要的是，他們（制憲先賢）究竟建立了什麼規範，而不是他們認為什麼才是正確解決衝突的方法。

{Q Is this distinction true?}

[p/111] 有時需挖掘史料，才能確認制憲者透過該規定所理解與表達之規範為何。但因史料既稀缺又不明，探索的結果可能存在著合理的不同解釋（reasonably disagreeing）。

兩段之前我曾說，解釋憲法文本即探問制憲或修憲者所欲建立之規範意旨為何…。然，吾人得以不同的語意，來詮釋某個憲法規定：探求系爭規定於今日所代表的意涵，或者其於今後所應代表的意涵。由於以下兩個因素結合的結果，最高法院無可避免地對某些憲法規定要採取第二種意涵：一、某些前提（或實踐）業已取得憲法基石的地位，即使制憲或修憲者本無意建立該項規範。二、美國憲法文化中有一種「文本主義者的敏感性」（the textualist sensibility），即法官如以全然非解釋性（即非文義）的方法進行審查（purely noninterpretive [i.e., nontextualist] review），將被認為是濫用權力，有損司法審查的正當性。

[p/112] 即使最高法院認為某個前提（或實踐）確實恐非制憲或修憲者所設立，但因其已取得憲法基石的地位，遂以某個憲法條文指稱之。即法院會將該前提置入（嵌入）某個文義上適切的憲法條文，並在此後以之代表該前提。例如，不論正當程序的「原始」理解為何，現在第 5 修正案的文句表示：凡依第 14 修正案適用於各州的反歧視規範（anti-discrimination norm），均適用於聯邦政府。

B. 解釋（具體化）憲法：

解釋憲法規定（文本）—探問制憲者或修憲者所欲建立的規範意旨為何，

不應與「探索依制憲／修憲者所信，如何解決目前困擾著我們的衝突方為正辦」相混淆。另一方面，解釋憲法規定（文本）也不應與「在某衝突的具體情境下，『認定』（specifying）相關但不確定之憲法規範之意旨」相互混淆。正如憲法₁≠憲法₂，憲法₁之解釋≠憲法₂之解釋。

假定大家都同意，相關（按：即系爭）的憲法規範是 X。如果所有同意 (a)系爭衝突的相關事實——所謂「裁決事實」(adjudicative facts)——為何，且 (b)其他相關法規範（如果有的話）為何，以及其他法規範對於該衝突的意義為何的人，不能合理地不同意 (cannot reasonably disagree)，按憲法規範 X 應如何解決系爭衝突的話，規範 X（的意旨）在該具體衝突情境下便是明確 (determinate) 的。

同理，如果所有同意前述(a)與(b)的人能合理地不同意 (can reasonably disagree)，按憲法規範 X，應如何解決系爭衝突，那麼規範 X（的意旨）就是不明確的 (indeterminate) 的，或者更精確地說是尚不夠明確的 (underdeterminate)。

規範 X 在某個（或多個）衝突情境中是明確的，不表示規範 X 在其他某個（或多個）衝突中也是明確的。如果規範 X 在某個衝突的具體情境中是不明確的，那麼 X 即應在該情境中予以「認定」(specified)。

[p/113] 在特定情境中，「認定」(specifying) 某個相關但（意涵）不確定的規範的過程，乃是判斷的過程 (the process of deciding)——判斷該規範（結合其他所有相關的考慮）在該具體情境中，應作何解釋。其為「形塑」(shaping) 規範的過程，亦即使該規範在某個衝突的具體情境下變得確定。適用意涵確定的規範 (applying a determinate norm)，基本上是個演繹的 (deductive) 過程；而認定某個意涵不確定的規範，基本上則是「非演繹的」(nondeductive) 過程。{Q 前者如「法則」(rule)之應用，後者如「原則」(principle)之應用？} 為某特定類型的案件認定一項原則時，並非自該原則為「演繹」(推論)，亦非在「發現」其隱含的意思；而是按照該原則之精神，考量其在實務上的可行性（或可強制執行性），並承認其與其他原則（或價值）有發生衝突之可能性…後，設定 (setting) 較為具體與類型化的要求 (more concrete and categorical requirement)。認定某項（意涵）不確定的憲法規範之挑戰（困難）在於：判斷 (deciding) 在某一個衝突的具體情境中，如何才能最佳地達成或體現 (how best to achieve or instantiate) 該規範核心的政治暨道德價值 (the political-moral value at the heart of the norm)；分辨 (discerning) 能夠獲致或體現 (achieving or embodying) 該價值的方法，亦即哪種方法最能調和政治社群在該衝突中所涉及的各種不同且時而相互衝突的利益。Anthony Kronman 所謂「判斷的過程」(the process of judgement) 恰可描述「不確定規範的認定過程」(process of specifying an indeterminate norm)。如是之「認定」就是一種「判斷」。

判斷幾乎不適用演繹（推論）的方法。判斷往往需要精緻的分析，但不限於精緻的分析。當吾人被迫需要在相互衝突的利益（或義務）中進行選擇（或調和）時，最需依賴判斷，而非「適用」某個位階較高的法則所能解決。

法院雖非面對「認定不確定法律規範」之挑戰的唯一政府機關，但確實經常面對此一挑戰。當法院被要求去適用某項法則 (rule) 時，它必須參酌該法

則制定者所不知道的資訊，**判斷該法則在新的情境下是什麼意思**。這是一項**創造性的決定**（a creative decision），涉及**裁量、各種後果之評估等**；簡而言之，就是一種「**立法的判斷**」（legislative judgment）...

{Q Perry 未如 Dworkin 與 Alexy，嚴格區分「**法則**」（rule）與「**原則**」（principle）？}

[p/114] 法律（存在）不確定性的事實，並因而有予「**確認**」之必要，是一件事；其價值為何，是另一件事：某個**政治社群（或其代議士）為何希望建立不確定的規範**？H.L.A. Hart 以為，這是「**人類困境的表徵（a feature of human predicament）**」...我們之所以使用一般（概括）的標準，去規範特定範圍的行為，而不進一步指示具體情境，實**因吾人對於事實的相對無知（our relative ignorance of the facts）**，及**對於目標的相對不確定性（our relative indeterminacy of the aim）**。」在這樣的困境下，許多規範相對不確定，其實是有道理的。

J. Cardozo 嘗謂：**憲法中有些規定，「並非針對過去而設的法則，而是針對綿延的未來而設的原則」**（not **rules** for the passing hours, but **principles** for the expanding future）。

[p/116] 例如：前述美國 1993 年「宗教自由回復法」...及[p/117] 1976 年歐洲人權法院（ECtHR）*Handyside Case*：就 ECHR Art. 10, Sec 2 所稱之「**道德**」（moral）按：指為維護健康與道德所必要時，得限制言論自由），各國固享有裁量餘地（a margin of appreciation），但仍須與歐洲人權法院之監督並行而不悖。

[p/118] 關於 1973 *Roe v. Wade* 案之討論甚多，但多未能區分**兩種不同性質之憲法解釋**：「**解釋憲法文本**，乃試圖分辨憲法文本所欲表彰之規範」（**interpreting a constitutional text**, in the sense of trying to discern what norm the text represents）與「**解釋憲法規範**=判斷在（某）衝突的具體情境下，應賦予**不確定規範**以如何之形狀」（**interpreting a constitutional norm**, in the sense of determining what shape to give the norm in the context of a conflict in which the norm is implicated but in which it is also indeterminate）。

[p/118~119] 有人試圖以下列兩點，質疑本人如上區分。一、以為所謂「**解釋文本 v. 解釋規範**」（interpreting a text v. interpreting a norm）即是在個案裁判中「**理解法律，而後適用法律**」（“understanding” a law and then “applying” a law）；二、（如 Hans-Georg Gadamer 所稱）「**理解法律恆為適用法律**」

（understanding ...is always application）。然而，前文主張的「**解釋文本 v. 解釋規範**」區分，並非「**理解 v. 適用**」的區分。我的主張「**解釋憲法規範=決定在衝突的具體情境下，應賦予不確定規範以如何之形狀**」，實際上是肯定 Gadamer 所稱「**理解恆為適用**」之洞見。我的主張假定：「**理解**」法規範的文本意思，即是「**適用**」該規範於當前的爭議=「**確認**」該規範在爭議之具體情境下的意思。

{按：Perry 同意 understanding=applying；其所欲闡釋者厥為：不確定規範之 understanding 需經 specifying, deciding, ascertaining and judging，始能得知其具體意思}

我之所以主張「解釋憲法**文本**」，乃試圖分辨憲法文本所欲表彰之規範」，乃因有些憲法規定乍看（初視）下是無法理解的（unintelligible），包括諱澀的（opaque）、模糊的（vague）、模稜兩可的（ambiguous）。

III. 最高法院最高？如是，最高法院解釋憲法時應如何（如果應）尊重其他憲法部門？

A. 最高法院最高？

[p/119] J. Brennan：「英國大憲章的高明之處及其長壽的秘訣，部分原因即在於它創造了**解決紛爭的機制**，迫使國王須服從男爵委員會的決定。凡文書將其執行權力完全委諸於承諾者之善意者，其價值鮮有高於其所書寫之羊皮紙者。」為求有效保障，以憲法設定規範時，應載有執行機制（enforcement mechanisms）。尤其，將規範載入憲法係因吾人對**多數決政治**保有懷疑時，更須如此。在美國，主要的執法機制就是司法審查，但並非因為我們相信最高法院必然較其他官員更能守護憲法規範。司法審查只是保護憲法規範的一種方式，有時它也未能守護憲法。

[p/120] 司法審查已成為美國憲政秩序的基石特徵，幾乎是自美國建國以來即有之。制憲者是否有意創設此一制度鮮少受到討論，普遍關注的是，此一權力應如何行使。支持司法審查的理念與實踐，並不表示當然支持司法至上主義（doctrine of judicial supremacy）。

前文（II. A.）已言：關於憲法₁的某些規定旨在表達什麼規範，容有合理的不同意見的廣泛空間。前文（II. B.）已言：關於憲法₂的某些規範，在特定情境下應如何「確定」其意思，也存有合理的不同意見的廣泛空間。兩者皆為關於「何為憲法₂所禁止者」之不同意見。{?}

憲法第3條固規定聯邦最高法院就其與各州法院關於「什麼是聯邦法（含憲法）所禁止」者，發生見解歧異時，具有裁判權。然，憲法並未（如其他國家憲法）規定，當聯邦政府各權力部門間，就「什麼是聯邦法（含憲法）所禁止者」，產生歧見時，應由哪個部門裁判。和許多公民（甚至最高法院大法官）所深信者不同，憲法₁並未規定聯邦最高法院對此具有裁判權，憲法₂也不包含具有此等效力之規範。

[p/121] 隨著時間的經過，一種期待油然而生，一種實踐應運而生，可名為「美國政治上的準憲法地位」（quasi-constitutional status in US Politics）——美國憲法文化中，有一種根深蒂固的期待：中央的立法與行政部門將避免從事聯邦最高法院宣示憲法禁止他們從事的事情，也會履行聯邦最高法院宣示憲法要求他們作為的事情，即使他們不同意聯邦最高法院關於「憲法禁止（或要求）他們作什麼」的見解。這樣的期待由何產生？

首先，我們逐漸相信這種期待是「可欲的」（desirable）——可使我們的政治生活少一些混亂，多一些生產力。基於務實的考量，總該有個機關有權決定什麼是憲法所禁止的。當然，基於務實的考量而為之同意（practical assent），不等於基於知識上或理論上的考量而為之同意（intellectual assent）。縱使前者為

必要，未必能導出後者亦屬必要。

其次，我們逐漸相信，就決斷「什麼是憲法所禁止的最低界限」(the minimum boundaries of what the Constitution forbids)而言，聯邦最高法院是最不讓人懼怕，而又最值得信賴的機關。注意，我說的是「最低限度」，而非「最大限度」。{Cf. 湯大法官德宗釋字 704 意見書}

[p/123] 說最高法院乃關於其自己與其他平行權力部門，關於憲法禁止什麼發生爭議時的仲裁者，非謂最高法院絕對不可歸結道：憲法將關於「某些憲法條文禁止什麼」的爭議，委由其他部門去解決{按：此即「政治問題」}；亦非謂最高法院，作為這種爭議的仲裁者，絕對不可聽從其他部門關於「憲法禁止什麼」的爭議的立場（詳見後述兩小節的討論）。{按：此涉及「審查基準」}

末應強調者，在憲法上，國會或總統均無義務須順從（聽從）最高法院關於「憲法禁止什麼」的見解（憲法判決）。順從（尊重）憲法判決的實踐僅具「準憲法」(quasi-constitutional)性質。最好將之理解為「推定式的實踐」(a presumptive practice)——在憲法上與道德上均屬正常的情況下的適當實踐。反之，在憲法上與道德上均不正常的情況下，國會或總統（甚或兩者均）不順從（尊重）聯邦最高法院的憲法判決可能是適當的。林肯總統在 1861 年發表第一次就職演說時，即處於憲法上與道德上均異常的情況下，謂：「如政府就影響全民存亡問題的決策，應毫無懸念地取決於聯邦最高法院的判決的話，…人民將不再是自己的主人，而是於此範圍內，實際上將他們的政府交給了卓越的法庭」。林肯此言乃針對最高法院惡名昭彰的 *Dred Scott v. Sanford* 案（認黑人非美國人民）判決而言。

B. 最高法院於解釋憲法時，應多麼尊重其他憲法部門？

[p/124] 如前所述，關於憲法₁究竟欲表述（傳達）什麼規範，存有「合理不同意」(reasonable disagreement)的廣泛空間。此時最高法院解釋憲法₁應該抱持著什麼樣順從（遷就）的態度？譬如，最高法院認為某項憲法規定應理解為在表述規範 X，而國會認為該項憲法規定應理解為在表述規範 Y 時，最高法院是否應順從（聽從）國會的意見？如果最高法院認為：國會的意見不僅是「錯誤的」(wrong)，而且通盤考量後是「不合理的」(unreasonable)，則期待最高法院應順從（聽從）國會的意見便是「不切實際的」(unrealistic)。當然，知識上高傲 (intellectually arrogant) 且政治上恣意 (politically willful) 的大法官可能無法分辨什麼國會觀點是「錯誤的」(wrong)，什麼是「不合理的」(unreasonable)。法院要順從國會？我以為，回答這個問題，首先應避免過度簡化（一般化），其次應考慮相關事項，尤其：

[p/125]

- 最高法院多數大法官就「國會意見不僅是錯誤的，且是不合理的」一節，到底具有多少自信？{按：指多數意見的比數？}

- 國會就系爭問題的思辨（討論）徹底到什麼程度？經過如何程序，而獲致結論？國會思考越徹底，最高法院越應順從。

{Q 是故，大法官宣告經覆議並維持的法案違憲，應有更高的可決門檻？}

• 國會的觀點是否在避免規範 X 對國會權力將產生較大的限制，而有所扭曲{按：即國會有無「自利」的考慮}？或者，規範 Y 將會對政府（包含國會）的權力產生較大的限制？於前者，國會的意見無異於在說：憲法₂禁止國會行動的範圍小於最高法院所說的，最高法院順從國會意見的正當性因而變弱。反之，於後者，國會的意見無異於在說：憲法₂禁止國會行動的範圍，較最高法院所說的更大，則最高法院順從國會意見的正當性遂變強。

• 依最高法院所見，何者（規範 X 或規範 Y）在政治道德上較具有吸引力？與之相關者，依最高法院所見，就規範之執行而言，何者（規範 X 或規範 Y）對法院較有吸引力？

G. 最高法院於解釋（確認）憲法₂時，應多麼尊重其他憲法部門？

[p/126] 此時，法院應扮演主要角色？抑或次要角色（如 James Bradley Thayer n. 74 所建議）？觀想前述歐洲人權法院關於各國應享有「裁量餘地」（margin of appreciation）的論述。如前所述，如果最高法院認為國會的意見不僅是錯誤的（wrong），而且（全盤考量後）是不合理的（unreasonable），期待最高法院應順從（聽從）國會的意見便是不切實際的（unrealistic）。同樣的，知識上高傲（intellectually arrogant）且政治上恣意（politically willful）的大法官可能無法分辨哪樣的國會觀點是「錯誤的」（wrong），哪樣是「不合理的」（unreasonable）。法院要順從國會？同樣應考慮相關事項，包括：

- 最高法院（多數）大法官認定「國會意見不僅是錯誤的，且是不合理的」，其票數與不同意見有多接近？
- 國會考慮（思辨）系爭問題徹底到什麼程度？
- 國會的觀點是否因其自身利益而受到扭曲？
- 國會是否（較法院）更適合「認定」系爭規範—例如事涉非關免於政府干預之消極權利（negative rights），而是要求政府提供援助，以滿足基本物質需要的積極請求權（positive entitlements）？{Q 功能最適理論？}
- 能否信任國會的「認定」程序可以公平、適當地處理規範之「認定」（X 或 Y 孰為最佳）問題？抑或系爭規範之認定「通常容易受到多數人的情緒影響」（usually vulnerable to majority sentiment），致政治上獨立的法院較可能公平、適當地處理？

同理，亦應注意避免一般化地推論（即不應一概認為）：關於不確定憲法規範之最適、最佳「認定」，法院應順從國會的觀點。

[p/127] 儘管危險，我願贊同某種一般化的方向。John Ely 教授在 **Democracy and Distrust** 一書並未談到，法院在「認定」不確定憲法規範時所應扮演的角色。他主要關心的是法院認定未列舉的基本權的問題，與本文所討論者不同；但其答案則有相關性。Ely 的主要論點為：「公共議題一般應由（理智的公民）所選舉的代議士以多數決（majority vote）來解決。」但有三類公共議題則主要應由法院以憲法問題來解決：

- (1) 關於「多數的理智公民（或其代議士）是否企圖以投票將其他理智公民排除於政治程序之外」，或「企圖將其政治影響力予以稀釋」的問題？
- (2) 關於「多數的理智公民是否制定管制體系，以圖利自身，而犧牲其他少數人之利益」的問題？
- (3) 關於「當多數理智公民作了一個涉及具有某種思想淵源的附帶約束（side constraint）的政治選擇時，該選擇是否違反該附帶約束——一個因為夠重要，且容易受到多數人的情緒影響，憲法（文件）乃將之付予超級多數（supermajority），以免將來被不足此一超級多數的多數所改變」的問題？

[p/128] Ely 的理論至少可以支持以下立論：從機關功能比較的觀點而言，法院（至少是聯邦法院）非常適合在「認定」權利或自由相關規範時，扮演主要角色，如果歷史經驗顯示這些規範「通常容易受到多數人的情緒影響」的話。

猶需補充者，我方才說的是法院最適合面對兩個「非不合理的」（not unreasonable）有關權利或自由的規範「認定」，而歷史經驗顯示這些規範「通常容易受到多數人情緒的影響」，必須擇一時：法院的認定，對受益者而言，較其他憲法部門之認定來得更有利時。當然，如果法院的認定，對受益者而言，不及於較其他憲法部門之認定來得更有利時，則另當別論。

[p/129] 當然，即便聯邦最高法院選擇在「認定」不確定的憲法規範上扮演主要角色，也可能有時因過於膽怯，致未能完全體現系爭規範的憲法價值。例如 J. Thayer 順從論的忠實傳人 J. Felix Frankfurter 在 *West Virginia State Board of Education v. Barnette* 案（宣告公立學校學童應一律向國旗敬禮的規定違憲）。他是該案唯一發表不同意見的大法官。案中 Jehovah's Witnesses 學童以宗教信仰為由，在良心上反對向國旗敬禮的規定。J. Frankfurter 堅信：這是一個人人對之可以有合理的不同意之判斷。正因為人們對此可以合理地不同，我認為憑著我的智慧觀點，悖於西維及尼亞洲的觀點，宣告系爭法規違憲，乃逾越我的憲法權力。

[p/130] Jeromy Waldron 認為，依據司法至上主義，來決斷什麼是憲法所禁止者之「司法審查」，從政治道德的觀點說，是大有問題的。

他排斥「加強版的人權清單實際上已使得法官以外的任何人，無法對之進行修改」的想法。這樣的說法，在英國政治暨法律文化下也許並不極端（偏激）。蓋英國並無「人權清單」，現在正在審慎考慮是否增設。但在美國的政治暨法律文化下，他的立場確實是極端（偏激）的。雖然如此，不表示他的意見絕非深思熟慮且重要（both thoughtful and important）。

[p/131] 我傾向於同意：制憲者在憲法中規定不確定規範時應該審慎；且國會與總統（如前 III.A 所述）在憲法上得不順從聯邦最高法院有關「何為憲法所禁止者」之判決，是一件好事。我無意否認國會與總統應推定司法為至上（presumptive supremacy），也不否認在憲法上與道德上正常的情形下，國會與

總統應順從司法的決定。我既不認同完全放棄「順從式的司法審查」(Thayerian practice of judicial review)，也不贊成完全沈溺於其中。我以為應採取中庸之道 (a “middle” way)。至少在某些不確定的憲法規範，應採取「非順從式的司法審查」。質言之，我主張就「通常容易受到多數人的情緒影響」之重要的權利或自由相關規範，應採取「非順從式的司法審查」。此一立場乃立基於「倘將違憲審查權委諸其他憲法部門行使，所可能導致的後果」的想像性（從而具有高度爭議性）的判斷之上。

[p/132] 我以為，我以上立場似頗能滿足 Bickel 教授所提出的著名判準：

其涉及政策制定的功能，但有別於立法與行政的功能；其特別適合法院的能力；如法院不願承擔，將無人為之；其能在一個普遍接受 (Hand 法官所稱) 「共益」(common venture) 意義下的社會中行使而被接受；於必要時，其會是有用的；其由法院行使不會因剝削其他憲法部門的尊嚴或負擔，而降低了他們的表現品質。

IV. 結語

[p/133] 欲探討當前最具爭議的道德衝突轉化為憲法衝突後，究竟是如何被解決的，吾人必須先回答本文前述三個先決而基本的問題。進行上開探索的理想環境，就是就特定的憲法爭議進行深刻的討論。特定爭議提供了必要的細節，既能用來展示 (exemplify) 在各個爭點上所採取的立場，也能用以證立這些立場。我最關心的憲法爭議則是二戰以來，法院關於憲法第 14 修正案禁止什麼樣的判決，例如涉及種族隔離、積極平權措施、性（為基礎）的歧視、同性戀、墮胎、及醫生幫助自殺的爭議。